



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. אלדד קולנשר
 2. תמר קולנשר
 3. מורן שניצר
 4. קרן רמי
 5. ינוב כרמלה
 6. לביא סיגלית
 7. מוטי סטרקובסקי
 8. ילנה ליבשיץ
 9. דייגי דרורה
 10. אילו קנפו בן נר
 11. אליהו קנפו
 12. רחל שטרית
 13. שמואל שטרית
 14. יוסף רבה
 15. אסתר הוניג
 16. אדוארד חדריה דוד
 17. ברוך צפדיה
 18. משה טיטלבוים
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד דורון רוזנברג
מדרך מנחם בגין 23 תל אביב

נגד

הנתבעים:

1. רוון ביזנס בע"מ
 2. מנחם רייז
 3. שירלי רייז
- הנתבעים 1-3 עוה"ד איתן ארז
מדרך מנחם בגין 23 תל אביב
4. חיים בליצקי
- מרחוב חרוב 4 מבשרת ציון

פסק דין

מבוא

הצדדים הינם כל בעלי הזכויות בבית ברחוב אושיסקין 44 תל אביב הבנוי על חלקה 63 בגוש 6963 (להלן: "הבית")



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עובדות שאינן שנויות במחלוקת הן כי בשנת 1995 החל הבית לשקוע כאשר מתגלים בו סדקים עמוקים. בשנת 1999 הכריזה עיריית תל אביב על הבית כ"מבנה מסוכן". גם עבודות מיסוד שבוצעו ע"י בעלי הדירות לחיזוק הבית לא הועילו ובשנת 2002 הוציאה עיריית תל אביב צו פינוי לכל הדיירים וצו הריסה לבית. סופו של יום בוצע צו ההריסה בנוגע לרבע מהבית. אולם, צו הפינוי נותר בעינו והכניסה והשימוש בבית אסורים מזה כעשור.

התובעים עותרים בתובענה למתן סעד על פי סעיף 60 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**) הקובע כלהלן:

"נהרס בית משותף, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא, ובעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (להלן - המשקמים) החליטו להקים את הבית מחדש או לתקנו, ישא כל בעל דירה בהוצאות הכרוכות בכך לגבי דירתו, ובעלי כל הדירות ישתתפו בהוצאות הכרוכות בכך לגבי הרכוש המשותף, כל אחד לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו".

לטענת התובעים, לאור הנסיבות שנוצרו עם הריסתו של הבית כאמור, פנו בעלי הדירות בהליכים לאישור תב"ע נקודתית במטרה להגדיל את שטחי הבניה ואת מספר יחידות הדור המותרות. כבר בהליך זה הערימו הנתבעים 1-3 (להלן: **"רייז"**) קשיים אשר העמידו בסכנה את אישור התב"ע כולה. סופו של דבר אושרה התב"ע בחודש 11/08. ערב אישור התב"ע כונסה אסיפה כללית של בעלי הדירות במסגרתה בחרו בעלי הדירות, לרבות הנתבעים, להקים את הבית באמצעות עסקת קומבינציה (לאחר שנשללו חלופות של מכירת הקרקע ובניה עצמית) ונציגות הבית הוסמכה לבצע עסקה כאמור. במשך תקופה ארוכה פעלה הנציגות לקבלת הצעות מחיר לביצוע העסקה, דא עקא, לא בנקל ניתן היה לאתר קבלן אשר יסכים לאחוזי הקומבינציה שהוצעו ולדרישה כי הוא יישא גם בעלויות המס של בעלי הדירות בעסקה. סופו של יום עלה בידי הנציגות להגיע להסכמה עם היזם גדי עמיאל (להלן: **"עמיאל"**) לביצוע עסקת קומבינציה לפיה בעלי הדירות יקבלו כ- 60% משטחי הבית החדש (כך שיוכלו לשוב לדירותיהם באותן קומות וכיוונים כפי שהיה במקור), עמיאל יבצע תכנון ניהול ופיקוח על העבודות, עמיאל יהיה רשאי לשלב בפרוייקט קונים פוטנציאלים, עמיאל יישא בכל עלויות המס החלות על העסקה, הפרוייקט יבוצע בתוך שנתיים וחצי מאישור אסיפת בעלי הדירות ועמיאל יעמיד ביטחונות בסכום כולל של 11 מיליון ₪. בין לבין הודיעו רייז כי הם אינם מעוניינים בעסקת קומבינציה אלא בעסקה של בניה עצמית, בניגוד להצבעתם באסיפה הכללית כאמור בעד עסקת קומבינציה.

לאחר השגת ההסכמות עם עמיאל כונסה ביום 09.02.10 אסיפה של בעלי הדירות להצגת העסקה לאישור. באסיפה זו התנגדו רייז לעסקה וטענו כי העסקה עם עמיאל איננה חוקית, כי ניתן לבנות בשטחים נוספים וכי הוגשה על ידם בקשה לפירוק הבית המשותף. בסופה של האסיפה הוחלט פה אחד כי תינתן לרייז שהות של 45 יום להודיע אם בדעתם להיכנס בנעליו של עמיאל על פי מתווה עסקה זהה הכולל ביטחונות משופרים (מיליון ₪ נוספים והערת אזהרה על דירות רייז בבית). רייז אף התחייבו למחוק את הבקשה לפירוק הבית המשותף. החלטת אסיפה בנוסח האמור נוסחה על ידי הצדדים ובאי כוחם ואושרה. בעקבות החלטה זו הודיעו רייז על כוונתם לממש את זכותם להיכנס בנעליו של עמיאל. אולם, חלף חתימה על הסכם על פי המתווה המוסכם, הציגו רייז הסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הכולל שינויים מהותיים במתווה ומו"מ שנוהל בין הצדדים (משך תקופה של כ- 7 חודשים) לא נשא פרי. סופו של יום הועבר לחתימת ריזי ההסכם שגובש עם עמיאל. ריזי לא מימשו את זכותם לחתום על ההסכם כזמנים לפרויקט ומשכך נחתם ביום 22.09.10 הסכם קומבינציה בין התובעים לבין עמיאל ושותפיו. התובעים טוענים כי ריזי עשו כל שבידם כדי למנוע את שיקום הבית ונהגו בחוסר תום לב לקידום עניינם בלבד ללא התחשבות בבעלי הדירות האחרים בבית.

התובעים טוענים כי הינם רוב של בעלי דירות בבית, להם צמודים 80.5% מהרכוש המשותף, אשר מעוניינים בהקמתו של הבית. בנסיבות אלו מבקשים התובעים כי אפעיל את סמכותי על פי סעיף 60(ב) לחוק המקרקעין.

לטענת ריזי הם אינם מסרבים להשתתף בהקמת הרכוש המשותף בבית אך המתווה שהציעו התובעים לקימום הבית אינו רציני, אינו ישים, אינו כלכלי ואינו מגובה בערבויות הולמות. ריזי טוענים כי, למעשה, אין מחלוקת בינם לבין התובעים, למעט אלו המשמשים כנציגות הבית – התובע 1 והתובע 3. ריזי מעוניינים לשקם את הבית באופן מיטבי עבור כל בעלי הדירות ולפיכך ביקשו לקבל מידע בנוגע להליכי הקימום ואף הראו נכונות לבצע בעצמם את קימום הבית (לאור התמשכות ארוכה של ההליכים). לאור הריסתו ופינויו של הבית הגישו ריזי בקשה למחיקת הבית המשותף ורק עקב מהלך זה הגישו התובעים את תביעתם דנן.

לטענת ריזי לא ניתן לחייבם בהתקשרות עם עו"ד סמואל משלא הסכימו להתקשרות זו ורוב בעלי הדירות כלל אינם מודעים להליכים שהתנהלו בנוגע לשיקום הבית. עו"ד סמואל התמהמה מאוד בטיפול באישור התב"ע מה גם שניתן היה לכלול הליך זה בהתקשרות עם היזם. ריזי טוענים כי עמיאל מבקש לעשות רווח בפרויקט וישנו חשש כי הוא אינו מסוגל לקומם את הבית. דא עקא, כאשר ניסו ריזי לברר פרטים אודות הפרויקט והביעו נכונות לקומם את הבית בעצמם, הסיתו חברי הנציגות את בעלי הדירות כנגדם.

ריזי טוענים כי האסיפה מיום 20.07.08 התכנסה לצורך החלטה בעניין תביעה כנגד העירייה. מכל מקום, ריזי הצביעו באותה אסיפה בעד בנייה עצמית בלבד. הנציגות לא הוסמכה לבצע עסקת קומבינציה ובודאי שהיה עליה להביא עסקה מיטבית.

לטענת ריזי המתווה שהוצע על ידי עמיאל עשוי היה להביא לחיוב בעלי הדירות בביצוע תשלומים מכיסם לקימום הבית. משכך, הם אלו אשר עמדו על כינוסה של אסיפה נוספת על מנת שיוכלו להציג בה את הצעתם לקימום הבית אשר הינה טובה יותר מהצעת עמיאל, לרבות, בטחונות טובים יותר והם אף הוכיחו יכולות כלכליות לעמוד בביצוע הפרויקט.

ריזי אינם מכחישים את אשר התרחש באסיפה מיום 09.02.10 ואת ההחלטה שנתקבלה במסגרתה. אולם, הם עמדו על זכותם להיכנס בנעליו של עמיאל ואף הציעו חוזה משופר על יסוד אותו מתווה. ריזי מדגישים כי החוזה אשר הוצע על ידם אינו שונה מהמתווה עליו הוסכם עם עמיאל והם אף נקטו צעדים ממשים לקראת הוצאתו אל הפועל. דא עקא, חברי הוועד הסיתו את בעלי הדירות כנגד ריזי ולא אפשרו קיום אסיפה עם בעלי המקצוע אשר שכרו ריזי לטובת שיקום הבית ולא נתנו לריזי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הזדמנות אמיתית לקיים את החלטת האסיפה מיום 09.02.10. על אף כל האמור לעיל טוענים ריז כי הם הסכימו לחתום על הסכם לקימום הבית, כפי שהוסכם עם עמיאל, אך התנגדו לכפיית יצוגו של עו"ד סמואל ותשלום שכר טרחתו.

לאור כל האמור טוענים ריז כי הצעתו של עמיאל איננה ישימה ולפיכך יש לדחות את התביעה כנגדם.

הנתבע 4 הגיש כתב הגנה במסגרתו טען כי הוא מעוניין בשיקום הבית בהקדם האפשרי ולפיכך ניסה, לכל אורך הדרך, לפשר בין הצדדים ולהביאם להסכמות. הנתבע 4 הודיע כי הוא סומך על שיקול דעת המפקח והודיע כי יצטרף לכל החלטת בנייה. הנתבע 4 טען כי בהצבעה באסיפה מיום 20.07.08 נמנעה ביתו (שייצגה אותו באותה האסיפה) לאור העדר זמן מספיק להתייעצות.

ביום 27.04.11 התקיים דיון מקדמי בתובענה ובסיומו נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות מטעם הצדדים. לאור עמדת הנתבע 4 בכתב ההגנה ובדיון בפני, פטרתי אותו מלהגיש תצהירי עדות ראשית ומלהתייצב להמשך הדיונים בתיק.

מטעם התובעים הוגשו תצהיריהם של התובעים 1, 3 ו-14, מר גדי עמיאל, מר עמי שטרית ומר דוד גוזלן. כן נתבקש זימונו של עו"ד אלון סמואל למתן עדות בעל פה. בהמשך ההליכים התרתי גם הגשתו של תצהיר מטעם מר עודד רוזנפלד.

מטעם ריז הוגשו תצהיריהם של מר מנחם ריז, עו"ד יצחק פרידמן, גב' אראלה בליצקי והשמאי יגאל אברהמוב.

ישיבות הוכחות נערכו בימים 12.07.11, 13.07.11 ו- 13.11.11. הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

דיון

סוגיה נדירה הובאה לפתחי לדיון בהליך דנן. נדירים הם המקרים אשר נכנסים בגדר תחולתו של סעיף 60 לחוק המקרקעין וכפועל יוצא ספורים הם המקרים אשר נדונו בפסיקה בהקשר זה.

פסק הדין היסודי של כבוד השופט חשין ברע"א 7112/93 בתיה צודלר נ' שרה יוסף פ"ד מח(5) 550 (להלן: "פרשת צודלר") הינו פסק דין מנחה ועיקרי בנוגע לבתים משותפים ככלל ובנוגע לסעיף 60 לחוק המקרקעין בפרט.

המחלוקת העיקרית שבין הצדדים הינה בנוגע לדרך שיקום הבית המתוכננת, קרי, האם ניתן לחייב את ריז לשקם את הבית על פי ההסכם שחתמו התובעים עם עמיאל. אולם, בטרם ניזקק להכרעה במחלוקת עיקרית זו, יש לבחון תחילה התקיימותם של שני תנאים ראשוניים לצורך הפעלת סמכויותיו של המפקח על פי סעיף 60 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

תנאי ראשון – "נהרס בית משותף"

סעיף 60 לחוק המקרקעין קובע תחולתו על מקרה בו "נהרס בית משותף, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא".

למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים בדבר התקיימות התנאי ובדבר הנסיבות העובדתיות אשר הביאו להריסתו בהתאם לצו הריסה שהוצא על ידי עיריית תל אביב.

נדמה כי נסיבות הריסתו של הבית לאור שקיעתו, כשלון עבודות המיסוד, הכרזתו כמבנה מסוכן ולבסוף הוצאת צו איסור שימוש וצו הריסה על ידי הרשות המקומית, תואמות את מטרתו של סעיף 60 לחוק המקרקעין, כפי שהובהרה בפרשת צודלר: "סעיף 60 מדבר, אמנם, במקום שבו "נהרס בית משותף... מכל סיבה שהיא..." (ההדגשה שלי - מ' ח'), ואולם אין ספק שכוונת הדברים היא, בעיקרו, למקרים חריגים כמעשה שמים (רעידת אדמה) או מעשה ידי אדם שלישי (כמו טיל אויב), לרבות אדם שהוא בעלים בבניין" (עמ' 568).

תנאי שני – החלטת בעלי הדירות

לצורך תחולתו של סעיף 60 לחוק המקרקעין נדרשת החלטה של ה"משקמים" - "בעלי דירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם".

הוכח בפני כי במקרה דנן נתקבלה החלטת משקמים בהתאם להוראות הדין.

בהתאם לצו רישום הבית המשותף, התובעים, למעט התובעים 7 ו-8, הינם בעלים של 565/761 חלקים מהרכוש המשותף בבית.

במסגרת ההליך דנן הובא לעדות בפני מר רוזנפלד, הבעלים הרשום של תת חלקה 3 בבית, לה צמודים 47/761 חלקים מהרכוש המשותף בבית, ואף הוא הביע את הסכמתו להליך השיקום, להסכם עם עמיאל ולהחלטה שהתקבלה בהקשר זה (ר' סעיף 4 לתצהירו). בעדותו הוא מאשר כי "אני חתמתי על הסכם הקומבינציה, אני נתתי יפויי כוח לעו"ד שלי בזמן המכירה לבצע את כל הפעולות שידרשו לעניין הבית הם חתמו מכאן נובע שגם אני חתמתי ועו"ד הדין שלי חתם על ההסכם שלי בשמי" (עמוד 48 שורות 11-13). מושכלות יסוד הן כי חתימתו של שלוח אשר הוסמך כדין (והשולח דנן מצהיר על כך) כמוה כחתימתו של השולח.

מעדותו של מר רוזנפלד עולה כי התובעים 7 ו-8, שהינם מוטבי הערת אזהרה, רכשו ממנו את כל זכויותיו בנכס עוד ביום 11.01.07 והסכם זה עודנו בתוקף. אף רוכשי הזכויות נתנו את הסכמתם וחתמו על ההסכם עם עמיאל.

יוצא כי בידי המשקמים הסכמה של בעלי דירות שלדירותיהם צמודים 80.4% מהרכוש המשותף בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אעיר בהקשר זה כי תמוהה בעיני טענת ריזו בסיכומיהם בכל הקשור לזהות הזכאי לאשר את השיקום בנוגע לתת חלקה 3. מחד טוענים הם כי התובעים 7 ו-8 (מוטבי הערת אזהרה בגין הדירה) אינם רשומים כבעלים ולכן אינם רשאים לקבל החלטה בנוגע לשיקום הבית בהתאם לסעיף 60 לחוק המקרקעין. מאידך טוענים הם כי מאחר והסכם עם עמיאל נחתם לאחר שמר רוזנפלד (הבעלים הרשום) מכר את זכויותיו בדירה, גם הוא אינו יכול להיות שותף בהחלטה על שיקום הבית, על אף שעודנו רשום כבעלים (סעיפים 17-18 לסיכומים). הטענות סותרות מניה וביה האחת את השניה – אם מכר מר רוזנפלד את זכויותיו בדירה לתובעים 7 ו-8 מדוע הם אינם יכולים ליתן ההסכמה בנוגע לפרוייקט? ואם נדרשת הסכמה של הבעלים הרשום דווקא (כגרסת ריזו) אזי מדוע מר רוזנפלד אינו יכול לתת ההסכמה, אף אם מכר את זכויותיו? אין כל ממש בטענה זו של ריזו וברי כי בעליה של תת חלקה 3, בין רוזנפלד ובין התובעים 7 ו-8, נתנו את הסכמתם לפרוייקט.

בסיכומיהם מעלים ריזו טענה כאילו לא עלה בידי התובעים להוכיח קבלת החלטת משקמים בהתאם להוראות הדין והתובעת 5 איננה בעלת זכויות בתת חלקה 1. לטענת ריזו המדובר בהשתלטות של תובעת 5 על רכוש משותף בבית ולמעשה לא קיים כל מחסן הרשום על שמה של התובעת 5 בפנקסי המקרקעין.

התובעים טוענים בסיכומי התגובה כי המדובר בהרחבת חזית אסורה, והצדק עימם.

ההלכה בעניין "הרחבת חזית" קובעת כי: "רשימת הפלוגתאות העומדת לדיון מעוצבת בכתבי הטענות שמגישים הצדדים. משכך, טענה שמעלה בעל דין שלא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה "שינוי חזית" או "הרחבת חזית", ויש לדחותה. יחד עם זאת מכיר הדין בשני מקרים בהם יותר שינוי חזית. הראשון הוא תיקון כתבי הטענות באישורו של בית המשפט, לפי תקנות 91 ו-92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, והשני הוא כאשר בעל הדין שכנגד נתן לכך את הסכמתו, מפורשות או מכללא (ע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ פ"ד נח(2) 145, 151 וכן ע"א 3199/93 קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ פ"ד מט(2) 843, 874-873 וע"א 759/76 פז נ' נוימן פ"ד לא(2) 169, 173).

לטענה האמורה אין כל זכר במסגרת ההליכים שהתנהלו בפני – לא בכתב ההגנה מטעם ריזו, לא בטיעוני הצדדים בדיונים שהתנהלו בפני ולא בתצהירים מטעם ריזו. רק במסגרת הסיכומים מטעם "נזכרו" ריזו להעלות את הטענה האמורה. די בכך להביא לדחייתה.

ויודגש, אין המדובר בטענה משפטית אלא בטענה לפיה מסמכי רישום הבית המשותף אינם משקפים את מצב הזכויות הקנייניות בבית לאשורם. ברי כי טענה זו צריכה היתה להופיע כבר בכתב הטענות מטעם ריזו. ברי גם כי טענה זו מחייבת ביסוס עובדתי (שממילא לא נטען ולא הוכח).

גם לגופם של דברים אין ממש בטענה זו.

התובעת 5 רשומה כבעלים של תת חלקה 1 בפנקס הבתים המשותפים, כפי שעולה בבירור מנסח הרישום שצורף. על פי מסמכי רישום הבית המשותף תת חלקה 1 הינה "מחסן" בשטח של 73 מ"ר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לה צמודים 73/761 חלקים מן הרכוש המשותף. אלו הן זכויות הקנייניות הברורות של התובעת 5 ולא ניתן לשלול אותן ממנה אך בהבל פה במסגרת הסיכומים.

רייז מבקשים לבסס את טענתם כי אין בידי התובעת 5 זכויות קנייניות בבית על כך שישנה אי התאמה בין היתר הבניה לבין תשריט הבית המשותף. דא עקא, ישנה הבחנה והפרדה ברורה בין דיני התכנון והבניה לבין דיני הקניין. **היתר הבניה איננו קובע ואינו יכול לקבוע דבר וחצי דבר לעניין זכויות הקניין בבית אשר מוסדרים, במקרה דנן, בפנקס הבתים המשותפים.**

מכל מקום, בהתאם להוראות ההלכה מחויב אני לדון בתובענה בהתאם למצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487). אם לטענת רייז רישום הבית המשותף אינו משקף את מצב הזכויות הקנייניות בפועל, הרי שעליהם לנקוט בהליכים המתאימים בפני הערכאות המוסמכות וכל עוד לא עשו כן **מצב הזכויות הרשומות בפנקסי המקרקעין הוא המחייב.**

אעיר כי טענה בדבר טעות ברישום הינה טענה המחייבת ביסוס עובדתי. טענה זו, מעצם טיבה וטבעה איננה יכולה להיות אך טענה משפטית. לפיכך, ממילא אין מקום לקבל טענה זו משלא הובאה בפני, ולו ראשית ראייה, כי הרישום שגוי. בהקשר זה, אף אם היתר הבניה אינו תואם את תשריט הבית המשותף, אין בכך ללמד על טעות כלשהי ברישום הזכויות הקנייניות – האם העובדה כי למן דהו אין היתר בניה לסגירת מרפסת דירתו הרשומה בפנקס הבתים המשותפים מלמדת על כי אין בידו זכויות הקניין באותה המרפסת? וגם בכיוון ההפוך, האם העובדה כי למן דהו ניתן היתר לבניה על גבי רכוש משותף מלמדת כי לו הזכויות הקנייניות לרכוש זה? התשובה, בהכרח, לשתי השאלות הנ"ל הינה בשלילה.

ועוד. חוק המקרקעין מגדיר "דירה" כ- "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר" (סעיף 52 לחוק). לפיכך, אף מחסן, ככל שהינו ממלא אחר ההגדרה האמורה, הינו בגדר "דירה" בהתאם להוראות החוק. משכך, אף שהנכס שבבעלות התובעת 5 הוגדר כ"מחסן" בצו רישום הבית המשותף, הרי שלאור תשריט הבית המשותף והיות ה"מחסן" יחידה שלמה ונפרדת, הרי שבהתאם להוראות חוק המקרקעין היא בעלת "דירה" בבית משותף והיא זכאית לקבל החלטה על פי סעיף 60 לחוק.

נוסף לכל האמור לעיל הרי שביום 09.02.10 נתקבלה החלטה פה אחד על ידי כל בעלי הזכויות בבית לפיה "מתווה התיקיה הירוקה לקימום הבניין שהוגש באסיפה ב- 09.02.10 מאושר" (מוצג י"א לתיק מוצגי תובעים). המתווה האמור הוא הסכם הקומבינציה עם עמיאל. רק בשלב מאוחר יותר התגלעו סכסוכים בין התובעים לבין רייז בנוגע לדרך השיקום המוצעת (אליהם נתייחס להלן). אולם, באותה האסיפה הוחלט פה אחד על מתווה השיקום. משכך, הרי שנתקבלה, למעשה, החלטת משקמים של כל בעלי הדירות בבית.

לפני סיום פרק זה אעיר עוד כי הנתבע 4 הצהיר בדיון בפני כי הוא לא נתן את הסכמתו בשל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסכסוך שבין הצדדים וכי "כל מה שיוחלט מקובל ואנחנו מעונינים בשיקום הבניין כמה שיותר מהר" (עמוד 2 שורות 14-15). משכך, ניתן לראות גם בו כמי שמצטרף להחלטת המשקמים.

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי נתקבלה החלטת משקמים כדין וברוב הדרוש.

"להקים את הבית מחדש".

עתה ניתן לבחון את עיקר המחלוקת שבין הצדדים בהליך דנן והיא גדר התפרסותו של הביטוי "להקים את הבית מחדש".

ניתן לסכם את טיעון התובעים בהקשר זה בתמצית כך שהחלטת המשקמים להקים את הבית בדרך של עסקת קומבינציה עם עמיאל הינה החלטה ראויה של בעלים סבירים שנתקבלה לאחר מיצוי הליכים, ללא אפליה ובתום לב.

מנגד, טענת ריז היא כי הם אינם מסרבים לשקם את הבית אולם דרך השיקום המוצעת איננה תואמת את הוראות חוק המקרקעין (שאינן מאפשרות כפיית הסכם קומבינציה), פוגעת בזכויותיהם הקנייניות, מפלה אותם לרעה והתקבלה בחוסר תום לב תוך הסתרת מידע. בהקשר זה נטען כי ישנה דרך אחרת לקימום הבית אשר מטיבה עם כל בעלי הדירות.

בטרם נכנס להכרעות עובדתיות בנוגע לנסיבות הספציפיות במקרה דנן, יש לבחון את המסגרת המשפטית בה עסקינן.

כאמור לעיל, פסק הדין בפרשת צודלר הינו פסק הדין המנחה בסוגיה. שם המדובר היה בבית אשר נהרס במהלך מלחמת המפרץ הראשונה והמחלוקת בין הצדדים היתה בנוגע לדרך השיקום – חלק מבעלי הדירות ביקשו לשקם את הבית על פי הסכם עם העירייה לפיו ימחו בעלי הדירות את כספי הפיצויים לעירייה ויוגדלו זכויות הבניה במתחם כך שאלו ישמשו כתמורה ליזמים אשר יבנו את הבית (תוך הגדלת דירות הבעלים) וימכרו את הדירות הנוספות בשוק החופשי. החלק האחר של בעלי הדירות סרב להסכם המוצע עם העירייה.

בפסק הדין בוחן השופט חשין את גבולותיו של המתחם הנורמטיבי שקבע המחוקק להקמתו של בית משותף שנהרס, תוך שהוא מתייחס למשמעות והיקף זכויות הקניין בבית המשותף.

השופט חשין מסיק כי זכויות הקניין בבית משותף אינן נכנסות למסגרות הקניין המסורתיות וזאת היות ועסקינן ביצור כלאיים אשר קיימות בו דירות בבעלות נפרדת ולצדן הרכוש המשותף בבעלות משותפת.

לאור האמור פוסק השופט חשין כי: "הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמאטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין. אין צורך שנידרש שאלה מה הוא עיקר בבית משותף: האם עיקר הוא הבעלות הנפרדת בכל דירה ודירה, והרכוש אינו אלא טפל לה; או אם עיקר הוא ברכוש המשותף בעוד שהבעלות הנפרדת כמו טפלה היא לו. לכל אלה ראה והשווה: ע"א 666/72 נ' סדובסקי ואח' נ' שמע ואח' [2]; ד"נ 20/73 שמע נ' נ' סדובסקי ואח' (פרשת סדובסקי [3]); טדסקי, במאמרו הנ"ל, בעמ' 224; פרופ' י' ויסמן, "יחד ולחוד בבית משותף" משפטים טז (תשמ"ו-מ"ז) 197, 202, 208-210. בין כך ובין אחרת, **זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית המשותף, ואין היא זכות הבעלות ה"קלאסית". בוודאי כך במקום שבו משותף נהרס** (בעמ' 563) (ההדגשה שלי, א.ס.).

מן האמור מגיע השופט חשין למסקנה כי:

"אכן, הקונספציה המסורתית של זכות הקניין לא יהיה בכוחה להוליך אותנו אל הסדר כגון זה הקבוע בסעיף 60 לחוק, ולא נוכל לגזור את זכות המשקמים לבנות את ביתם מחדש מתוך זכות הקניין. אם תחנת המוצא שלנו תהא בזכות הקניין, באשר היא - וזו כנראה הנחתו של פרופ' טדסקי - מסקנה נדרשת מאלה היא, שהסדר סעיף 60 פוגע בזכות הבעלות. סעיף 60 אינו בונה עצמו - מעיקרו של דין - על זכות הקניין בלבד, שהרי זכות הקניין באשר היא אין בכוחה כדי לחייב בעלים במשותף של קרקע לבנות על אותה קרקע בית שנהרס. ואם בכל זאת בחר המחוקק בפתרון שיקומו של הבית, נדע כי כבש לעצמו דרך חדשה, דרך שאינה דרך הקניין בלבד. וכשם שמתחילה הציב הבית המשותף לפנינו מודל נורמאטיבי מיוחד, כך הוסיף המחוקק וראה להדגיש אותה מיוחדות בנסיבות החריגות של הרס הבית המשותף. **זאת עשה בקביעת נורמת השיקום. הסדר זה של שיקום אינו נגזר, כאמור, מזכות הקניין הקלאסית, ואין הוא מהווה חלק אינהרנטי מתורת הקניין הקלאסית. אדרבא: ההסדר נותן יתר משקל לשיקולים שהם לבר-קנייניים קלאסיים, ויוצר הוא חריג בולט לתורת הקניין הקלאסית.** ומתוך שעוסקים אנו במודל העומד לעצמו, לא ניחרד מהתערבות עמוקה של ההסדר בזכויות הבעלות הקלאסיות, אף לא בזכויות הבעלות המיוחדות שבבית המשותף. התערבות זו היא רצונו המפורש של המחוקק, ולדבריו נישמע" (עמוד 565) (ההדגשות שלי א.ס.).

לאור האמור לעיל מכריע השופט חשין כי יש ליתן לביטוי "הקמה מחדש" פירוש תכליתי שמשמעו הקמתו של "בית משכן לאדם" ולא "כמכוון עצמו אך להקמתו מחדש של אותו מבנה עץ ואבן", כאשר מתחם שיקול הדעת של המשקמים ייבחן על פי "הבעלים הסביר" - "שיקול-דעתו של בית המשפט אם בנסיבות העניין הספציפי החלטתם של המשקמים הייתה החלטה ראויה של בעלים סבירים" (עמ' 566).

למבחן הסבירות מציע השופט חשין מבחני עזר - השוואת שווי הזכויות על פי חלופת ההקמה לחלופת אי ההקמה ופירוק השיתוף, שמירת השוויון בין בעלי הדירות ואי הפליה ופעולה בתום לב והגינות (עמ' 570-569).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

פסק הדין בפרשת צודלר שימש בסיס לפסק דין בע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת קלצ'וק") העוסק בחוק המקרקעין (חיזוק בתי משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק"). פסק דין זה אושר בפסק דינו של כבוד השופט רובינשטיין ברעא 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון (פורסם בנבו).

השופט כהן מאמץ את גישת השופט חשין בנוגע לתפיסת זכות הקניין בבית משותף ופוסק כי "תפיסת דיני הקניין בישראל זנחה במידה רבה את "הגנת החבות" ("Liability Rule"). הגנת החבות (או בשמה האחר - הגנת האחריות), מעקרת את זכות הווטו של המיעוט, העלולה למנוע השאת התועלת לכלל השותפים. עם זאת, מקום בו התועלת לכלל גורמת לפגיעה במיעוט, יהיה המיעוט זכאי לקבל פיצוי על הפגיעה בזכותו הקניינית. הפעלת הגנת החבות, עשויה במקרים המתאימים לשמש כלי יעיל לאיזון בין זכויות קנייניות סותרות (וראה: ספרם של William M. Richard A. Posner, "The Economic Structure of Tort Law", 1987, & Lands Guido and Fellows of Harvard College, page 29 by the President Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules and Calabresi & Inalienability, Harvard Law review, vol. 58 (1972) page 1089 (סעיף 15 לפסק הדין).

ובהמשך מאמץ הוא את מבחני המשנה שנקבעו על ידי השופט חשין לבחינת הסבירות בקבלת ההחלטה הכפויה על המיעוט בהקשר לחוק החיזוק.

"עתה נחזור ל"פס"ד צודלר". כאשר יינתן היתר הבניה, והמיעוט עדיין יעמוד בסרובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון, והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם "הפיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. מעל לכל, אם ימצא המפקח מקום לכך, יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי. המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פיחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר" (סעיף 18 לפסק הדין).

אומנם, פרשת קלצ'וק עניינה בחוק החיזוק. אולם, נקודת המוצא להכרעת השופט כהן שם היתה תפיסת הקניין בבית המשותף כפי שזו משתקפת בפרשת צודלר והתאמתה להוראות חוק החיזוק הנ"ל. תפיסת הקניין כפי שמוצאת ביטוי בפרשת קלצ'וק יכולה לחזור ולהשליך גם על הוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין בו עסקינן. העיקרון המשפטי העומד בבסיס שני ההסדרים החקיקתיים הנ"ל זהה.

אעיר כי גישה זו גם שימשה בסיס והסבר לחקיקתו של חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו – 2006, כפי שפורט בהרחבה בפסק הדין בע"א 51373-01-11 נבט נ' אנוך ואח' (פורסם בנבו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כבר כאן המקום להדגיש כי אין בידי לקבל את טענת רייז כאילו לא ניתן לחייבם בהתקשרות בהסכם קומבינציה בגדרו של סעיף 60 לחוק המקרקעין. בהקשר זה נקבע בפרשת צודלר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי - "הסדר סעיף 60 הוא הסדר כפוי, וכשם שכפוי הוא מעיקרו לעניין הקמתו מחדש של בית, כן יהיה הוא כפוי לעניין הדרך שבה ייבנה הבית" (עמ' 566). כלומר, לא רק שאלת עצם שיקומו או אי שיקומו של הבית היא העומדת לבירור בתובענה על פי סעיף 60 לחוק המקרקעין. בהקשר זה רייז אומנם אינם בגדר סרבן, עת שהסכימו ומסכימים הם לקימום הבית. אולם, רייז הינם "סרבנים" בכל הקשור לדרך שבה בחרו המשקמים לקומם את הבית. גם דרך השיקום נכללת בגדר הבחינה הנדרשת לתחולת הסעיף.

מתוך מסכת משפטית זו עלינו לצאת להכרעה בתובענה דנן ולקבוע האם החלטת השיקום שהתקבלה הינה החלטה ראויה של "בעלים סביר" על פי מבחני המשנה שהותוו כאמור.

השוואת שווי הזכויות על פי חלופות השיקום

להוכחת טענתם בדבר פגיעה בזכויותיהם הוגשה מטעם רייז חוות דעתו של השמאי יגאל אברהמוב.

מחוות הדעת עולה כי לשיטתו של מר אברהמוב לרייז נגרם נזק בשיעור של 815,571 ₪ בהשוואת העסקה המוצעת לבין חלופה של קימום הבית באמצעות הזמנת שירותי בניה (סעיף 11.1). דא עקא, אין בחוות הדעת בהקשר זה כדי לסייע לרייז.

מושכלות יסוד, וגם אין מחלוקת אמיתית בין הצדדים בהקשר זה, כי עסקה של הזמנת שירותי בניה הינה העסקה הכדאית ביותר עבור בעלי הדירות (ר') גם עדותו של עו"ד סמואל בעמוד 22 שורות 24-25). לו היתה החלטה של בעלי דירות בבית שלהם צמודים 75% מהרכוש המשותף, לבצע את קימום הבית באמצעות הזמנת שירותי בניה, ברי כי ניתן היה לאשר חלופת שיקום זו במסגרת הוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין ואף לכפות על המיעוט, אף אם הוא חסר אמצעים כלכליים, לשאת בחלקו או לחייבו להעביר את זכויותיו לאחר בהתאם להוראות סעיף 60(ב) לחוק.

באסיפה מיום 20.07.08 הצביעו בעלי הדירות על חלופות דרכי הקימום המוצעות. בהצעה לביצוע בניה עצמית תמכו בעלי דירות שלהם 290/761 חלקים צמודים מהרכוש המשותף בלבד (מוצג ה' לתיק מוצגי התובעים). לפיכך, לא היה רוב נדרש של בעלי דירות בבית כאמור אשר ביקש לבצע את קימום הבית בדרך האמורה.

כך מעיד עו"ד סמואל בנוגע לישיבה האמורה - "נושא הבניה העצמית נפסל ברוב של 8 דיירים נגד 5 תומכים ונמנע אחד. לאחר מכן, הועלתה האפשרות של מכירת המגרש מול עסקת קומבינציה וברוב של כל הנוכחים למעט שלושה בעלי דירות סטרוקובסקי, קרן דולב ואלדד קולנשר שנמנעו ומורן שניצר שתמך בעסקת מכר, כל השאר, 11 בעלי דירות, תמכו בעסקת קומבינציה ולפיכך הוסמכנו לפעול בסיכום הישיבה. ש.ת. בהצבעה הראשונה על בניה עצמית אדון רייז תמך בנושא של בניה עצמית, בהצבעה השנייה בין קומבינציה למכר, רייז תמך בקומבינציה" (עמוד 13 שורות 8-13). עו"ד סמואל אף הסביר מדוע נפלה, במקרה דנן, ההצעה האמורה - "הנימוקים היו בעיקר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הצורך לקבל מימון בנקאי בעסקה של בניה עצמית. לא כל בעלי הדירות הם מחתך סוציו-אקונומי שהפרוטה מצויה בכיסם והם לא יכולים לשלם מכיסם. היו לפחות שלושה מקרים על הגבול הסוציאלי כולל כאלה שיש להם עיקולים וברור שהבנק לא ייתן להם הלוואה ולחלק מהאנשים היו משכנתאות על הדירות כך שהיכולת לבצע בניה עצמית הייתה למעשה לא קיימת. לעומת זאת, בעסקת קומבינציה, אנחנו הבנו שניתן לעשותה מבלי להוסיף כספים ליזם או לקבלן וזו נראתה לנו להדרך האופטימאלית כי הרבה מבעלי הדירות רצו ורוצים לחזור ולגור בבניין הזה" (עמוד 13 שורות 14-19).

כך גם מעיד מר קולנשר – "אתה מושך לאבסורד. 8 אנשים הצביעו נגד האופציה הזו ואלו אנשים שקשה להם ולכן הוחלט שלא להזמין שירותי בניה. זה המספר שאני זוכר. ש.ת. בודדים הצביעו בעד, אני יכול לבדוק, אני לא בטוח שחמישה" (עמוד 34 שורות 27-29).

ואדגיש, **השוואת שווי הזכויות על פי חלופות השיקום חייבת להיעשות ביחס לחלופות רלבנטיות וממשיות ולא ביחס לציפיות חסרות סיכויי התממשות בפועל.** בהעדר רוב נדרש של בעלי הדירות כאמור המבקשים לקומם את הבית בדרך של הזמנת שירותי בניה, אין כל היתכנות חוקית לקימום הבית בדרך זו.

לפיכך, בחינת ה"נזק" לשווי הזכויות של ריז בין העסקה המוצעת לבין קימום הבית בדרך של בניה עצמית איננה רלבנטית. ברי כי לכל בעלי הזכויות בבית נגרם "נזק" כאשר הבית אינו מוקם בדרך של בניה עצמית. דא עקא, הסדר סעיף 60 לחוק, כפי שפורש בפרשת צודלר, "נותן יתר משקל לשיקולים שהם לבר-קנייניים קלאסיים ויוצר חריג בולט לתורת הקניין הקלאסית" ובתוך כך מאפשר לרוב מיוחד של בעלי דירות "מרחב מחיה ראוי שבו יוכלו לממש את רצונם ולבנות מחדש את משכנם" (עמוד 565).

ויודגש, במקרה דנן, כפי שרייז טוענים לכל אורך הדרך, אין הם מתנגדים לקימום הבית. ריז אף מבהיר זאת במפורש במסגרת עדותו – **"אני מעוניין בשיקום הבניין, אני הראשון לנו יש את החלק הכי גדול בבניין"** (עמוד 59 שורה 12).

הדברים נכונים גם בנוגע לחלופה המוצעת על ידי ריז לביצוע עסקה משולבת של הזמנת שירותי בניה על ידם מחד (לרבות בניה של זכויות הבניה הנוספות המגיעות להם על פי חלקם היחסי) ועסקת קומבינציה על ידי יתר בעלי הדירות בבית מאידך.

אומנם, הצעה זו לא עלתה להצבעה במסגרת האסיפה מיום 20.07.08. אולם, לא עלה בידי ריז להוכיח כי ישנה הסכמה להצעה זו של רוב נדרש של בעלי הדירות בהתאם להוראת סעיף 60 לחוק. כל בעלי הדירות בבית הינם צד להליך בפני ולא עלה בידי ריז להוכיח כי למעט הנתבע 4 יש עוד מי שמסכים, לכאורה, לחלופה האמורה.

גם לא עלה בידי ריז להוכיח כי המדובר בחלופה שלה היתכנות ממשית בנסיבות דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, חוות הדעת של מר אברהמוב עוסקת בחישוב שווי זכויות בלבד במנותק ממגבלות תכנוניות לביצוע בפועל. אין בחוות הדעת התייחסות לאפשרות תכנונית לביצוע קימום הבית באופן כזה שבידי ריז יתקבלו שטחים בנויים כפי שנטען כי הם זכאים להם בעוד בעלי הדירות האחרים יוכלו לקבל בחזרה את דירתם במקום בו היתה. לא הוצגה בחוות הדעת המשמעות הכלכלית של מהלך משולב כזה על "שווי" הזכויות של בעלי הדירות האחרים או אם ישנה בכלל כדאיות כלכלית בסיסית ליזם בעסקה על פי מתווה זה.

שנית, לא הוצגה בפני כל חוות דעת אדריכלית המבססת את טענת ריז כי ניתן בפועל לתכנן ולבצע עסקה משולבת במסגרתה יקבלו ריז דירה בבית הכוללת את תוספת הגודל על פי חלקם היחסי בזכויות הבניה. גם לא הוכח כי אם מי מבעלי הדירות האחרים יחפוץ גם הוא בעסקה משולבת האם ניתן יהיה בכלל להוציאה אל הפועל כך שכל בעלי הדירות ישובו לדירותיהם.

אעיר כי מן הראיות שבפני עולה שהוספת שטחים לדירת ריז כאמור תביא, מניה וביה, לכך שלא כל בעל דירה בבית יקבל בחזרה את דירתו המקורית ובמיקומה. זו היתה נקודת המוצא של בעלי הדירות לקימום הבית. זו גם נקודת המוצא של סעיף 60 לחוק המקרקעין.

דווקא דרך השיקום המוצעת מביאה לתוצאה האמורה – "כל דייר מקבל פחות או יותר את הדירה שהייתה לו ועמיל מקבל את כל הדירות שלמעלה" (עמוד 33 שורה 16).

שלישית, גם לא עלה בידי ריז להציג בפני ולו **הצעה קונקרטית אחת** של יזם אשר מוכן לקחת על עצמו את הפרוייקט ה"משולב" כאמור בדרך כלשהי, אף מבלי להשיב לבעלי הדירות את דירותיהם המקוריות. יותר מכך, מעדויות מר ריז ומר פרידמן עולה כי לא נעשו כל פניות ליזמים או לקבלנים לבחינת ההיתכנות לביצוע עסקה משולבת. אפילו לא נעשו בדיקות השוואה בין חלופות עסקאות קומבינציה (עמוד 55 שורה 23).

למרות טענות עו"ד פרידמן בעדותו כי עסקה מעין זו נפוצה בעשרות או מאות (עמוד 61 שורות 8-9), לא הוצגה בפני ולו עסקה אחת על פי מתווה כאמור, ובודאי שלא עסקה שנתונה העובדתיים (מבחינת היקף זכויות הבניה והמגבלות התכנוניות והפיזיות) דומים.

מאידך, העידו בפני חברי הנציגות אשר ניהלו מו"מ עם יזמים שונים במהלך השנים ומעדותם עלה כי לא היתה כל התכנות לעסקה משולבת. כך מעיד מר קולנשר – "האופציה הזו של קומבינציה ושרותי בניה יחד לא עלתה באסיפת הדיירים היה לנו ברור כבר בשלב הזה שזו אופציה לא מעשית כי היה לנו ניסיון קודם לנסות להגיע לעסקה של קומבינציה עם יזמים וזה היה לפני שקיבלנו את התב"ע וראינו מה אנשים מציעים ולא הצלחנו. הדרך היחידה להגיע להסכם אז היה להוסיף סכום אמוד גדול מכל אחד מהדיירים והמנדט שהיה לנו מהדיירים היה להגיע לעסקה שלא צריך להוציא כסף מהכיס. התב"ע הוסיפה בעצם רק 4 דירות ולכן ידענו שהמנוף שיש ליזם בשביל להקים את הבניין הוא לא מספיק, כי אם עושים חשבון כמה יזם מקבל, ידענו שאין לנו מנוף מספיק לקומבינציה ואם מישו רוצה לעשות בניה עצמית זה מבטל לגמרי את המנוף לקומבינציה גם מר ריז לא העלה את זה, אף אחד לא העלה את זה" (עמוד 34 שורות 13-20) (ההדגשה שלי, א.ס.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ובהמשך "עסקת הקומבינציה לפי נחמה בוגין היא לא כדאית ליזם כי אין לו רווח וזו הייתה הבעיה שלנו כוועד כי קיבלנו מנדט כמעט בלתי אפשרי. הוא מקבל שטחים לא מספיקים וגם משלם את כל המיסים בעצם רק יזם שרצה לגור שם היה מוכן להיכנס לסיפור הזה יכול להיות שהוא מרוויח בשוליים. היה יזם נוסף, אורבניקה, הגיעו איתנו להסכם דומה הוא אמר שהם רוצים לגור שם, זו המוטיבציה שלהם" (עמוד 35 שורות 18-22). כך מעיד גם מר סמואל - "במגרש הזה אין מספיק זכויות בניה, ולכן לא הצענו את זה" (עמוד 22 שורה 27). עדויות אלו לא נסתרו בחוות הדעת של מר אברהמוב.

זאת ועוד. על פי חוות הדעת של מר אברהמוב יוצא כי לרייז זכאות לחלקי דירה נוספת בבית שיוקם (סעיף 9.ח). משכך, המדובר בחלופה זו בשותפות כפויה בבעלות בדירה בין רייז לבין היזם אשר יבנה את הפרויקט במסגרת הסכם הקומבינציה עם יתר בעלי הדירות. האמור אך מקטין עוד יותר את הסיכוי למציאת יזם אשר יסכים ליטול על עצמו התקשרות מסוג זה. אעיר כי גם אין כל התייחסות בחוות הדעת למשמעות שותפות צפויה זו על שווי הזכויות על-פי החלופה המשולבת המוצעת על ידי רייז.

למעשה, גם רייז הבינו כי אין התכנות ממשיית לעסקה משולבת ואף הם הסכימו לעסקה נשוא התובענה דנן. כך, באסיפה מיום 09.02.10 נטשו רייז את דרישתם לעסקת בנייה עצמית והוחלט במפורש, בהסכמה בין כל הצדדים, כי: "מתווה התיקיה הירוקה לקימום הבניין שהוגש באסיפה ב- 09/02/10 – מאושר (ללא התרשימים). ניתנת אפשרות למר מנחם רייז להגיש מתווה זהה ... במקרה שמר רייז לא יגיש הצעה כאמור לעיל תוך 45 יום, כל בעלי הדירות מאשרים פה אחד את ביצוע המתווה של התיקיה הירוקה על-ידי מר עמיאל. במקביל מר רייז מודיע שהוא מוחק את הבקשה לפירוק הבית המשותף ולא יחדשה במקרה שלא יגיש הצעה כאמור לעיל" (נספח יא למוצגי התובעים וראה גם עדותו של מר שטרית בעניין זה בעמוד 31 שורות 1-3).

למעלה מכך, גם לאחר שהמשיכו הצדדים במו"מ ולמרות חילוקי הדעות, הסכימו רייז לחתום על ההסכם כלשונו (למעט סוגיית שכ"ט עוה"ד). כלומר, רייז הסכימו באופן מפורש לחלופת שיקום הבית כפי שזו מבוקשת במסגרת ההליך דנן ונטשו את בקשתם לעסקה משולבת או לפירוק השיתוף (מוצג כא' למוצגי התובעים).

משכך, עלינו להשוות בין ערכן של הזכויות על פי שתי חלופות בלבד – קימום הבית על פי המתווה הקיים או ביטול רישום הבית המשותף ופירוק השיתוף.

נדמה כי אין מחלוקת אמיתית בין הצדדים כי בין שתי החלופות האמורות החלופה של קימום הבית הינה העדיפה. אומנם, רייז הגישו בקשה לביטול רישום הבית המשותף. אולם, הם שבו והבהירו, כפי שגם מצוטט לעיל, כי הם מעוניינים בשיקום הבית. הם גם נתנו הסכמתם כאמור לעיל לפרויקט, אפילו במתווה הקיים (למעט סוגיית תשלום שכ"ט עוה"ד סמואל ולכך ניזקק להלן). אעיר בהקשר זה כי התנגדותם עתה למימוש מתווה לשיקום בניגוד להסכמות שניתנו על ידם ובניגוד להסכמתם לחתום כזמנים על הסכם לביצוע השיקום איננה מובנת. מכל מקום, הוכח גם כי מתווה השיקום לא גורע משווי זכויות רייז אלא משפרן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי חוות דעתו של מר אברהמוב שווי הדירה המוצעת לרייז במסגרת ההסכם הינו כ- 3,520,000 ₪ לפי שווי של 32,000 ₪/מ"ר. כל העדים שהעידו בפני הסכימו כי שווי מ"ר בנוי באיזור נע בסביבות מחיר זה (ר' עמוד 23 שורה 5 ועמוד 41 שורה 23). לפיכך ניתן לומר כי ההערכה האמורה סבירה וזהו שווי הזכויות הצפוי לרייז בחלופת קימום הבית המוצעת (ללא חניה). ויודגש, במסגרת חלופה זו לא נדרשים רייז לבצע כל תשלום נוסף.

מר אברהמוב מעריך את עלויות הבניה בסך של 5,800 ₪/מ"ר. העדים שהעידו בפני הסכימו כי עלות מטר בניה הינה בגבולות של כ- 6,000 ₪/מ"ר (עמוד 23 שורה 4, עמוד 37 שורות 5-6 ועמוד 42 שורה 23).

עוד עולה מחוות הדעת כי על פי התב"ע ניתן לבנות בבית עד 1,083.5 מ"ר שטחים עיקריים ובנוסף לכל יח"ד ניתן להוסיף ממ"ד בגודל 12 מ"ר (20 כפול 12 שווה 240 מ"ר). סה"כ שטח לבניה כ- 1,323 מ"ר, בין בבניה עצמית ובין בעסקת קומבינציה (עמוד 49 שורה 16). נתון זה תואם את עדותו של עו"ד סמואל (עמוד 22 שורה 1).

מעדותו של מר עמיאל עולה כי עלויות הבניה הצפויות ליזם (ללא החניות) עומדות על סך של כ- 20 מיליון ₪ (על בסיס עלויות שירותי בניה, מיסוי שבח והשבחה, שכר יועצים, עלויות מימון, ניהול פרוייקט וכיוצ"ב – עמוד 42 שורה 25 עד עמוד 43 שורה 4). ובחלוקה לפי 1,600 מ"ר לבניה על פי חישוב עמיאל (עמוד 42 שורה 20, נתמך גם בעדות סמואל בעמוד 27 שורה 1), עלות בניה ליזם הינה בגבולות 12,500 ₪/מ"ר.

יוצא כי בפירוק השיתוף ומכירת הזכויות ליזם (בעסקת נטו, כמו זו המוצעת בחלופת השיקום דנן) יוכלו בעלי הדירות לקבל תשלום בגבולות של כ- 19,500 ₪/מ"ר (32,000 פחות 12,500) וזאת מבלי לחשב כלל הפחתה של רווח יזמי ומע"מ (בשיעור של 16%) הכלול במחיר שווי הזכויות. נתון זה נתמך בחוות הדעת של מר אברהמוב במסגרתה הוא מעריך שווי מ"ר מבונה בסך של 19,000 ₪ (טבלה בסעיף 10 לחוות הדעת).

לרייז זכויות ב- 145 מ"ר שטח עיקרי (102/761 כפול 1,083.5) ועוד 24 מ"ר שטחי ממ"דים. לפיכך יהיו זכאים, במקרה המקסימלי, בחלופת פירוק השיתוף לתשלום בגין זכויותיהם בגבולות של 3,211,000 ₪.

כלומר, העסקה לקימום הבית איננה גורמת לפיחות זכויות רייז בהשוואה לחלופת פירוק השיתוף והיא אף משפרת את שווי זכויותיו. ויודגש, אף אם החישוב האמור מוטה במספר אחוזים לכיוון זה או אחר (בפרט כאשר לא חושבו רכיבים משמעותיים של רווח יזמי ומע"מ), עדיין ברור כי מבחינת שווי זכויות הצדדים, חלופה של קימום הבית עדיפה על פני חלופה של מחיקת הרישום ופירוק השיתוף. בפרט כאשר למערך החישובים יתווספו עוד שיקולי מס בחלופה של פירוק שיתוף ומכירת הזכויות בעוד שבעסקה המוצעת נושא היזם במרבית, אם לא בכל, עלויות המס הצפויות (סעיפים 36-38 להסכם הקומבינציה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

למר אברהמוב טענה נוספת והיא כי במסגרת הסכם של הזמנת שירותי בניה יכלו ריזו לרכוש מקומות חניה במרתף מבעלים אחרים בעוד בהסכם עם עמיאל נותר האחרון בעלים של חניות שבעלי הזכויות לא נשאו בעלות מימון בנייתם. אין ממש בטענה זו.

בכל הקשור לחניות קובע ההסכם עם עמיאל כי האחרון יממן את עלות בניית המרתף בכללותו וכי בעל דירה אשר יהיה מעוניין בכך יוכל ל"רכוש" זכויות בחניה ע"י תשלום עלויות הבניה בלבד (סעיף 31 להסכם). כך מסביר מר קולנשר את ההסכם בהקשר זה – "בהתאם להסכם עם עמיאל אמור לקבל 10 חניות וכל השאר שלנו. הן מיועדות לדיירים כאשר תהיה הגרלה וכל דייר שיבחר. אם יהיו מספיק אנשים שרוצים, יצטרך לשלם את עלויות הבניה ולא שקל יותר. אם אף אחד לא ירצה חניה יש סעיף שאומר שעמיאל יצטרך לממן את זה" (עמוד 35 שורות 1-3 וראה גם סעיף 31 להסכם הקומבינציה מוצג כג' לתיק מוצגי התובעים).

דווקא בנוגע לחניון המדובר בעסקה פשוטה של שירותי בניה מופחתים – עלויות בניה בלבד. העובדה כי עמיאל יקבל את כל החניות בבית אם לא יהיה מי מבעלי הדירות אשר יהיה מעוניין לשלם עבור עלויות הבניה אין בה להעלות או להוריד. הזכות היא בידי בעלי הדירות בלבד להחליט אם רצונם במימון חניה אם לאו, כשם שזכותם היתה להחליט (בעסקה תיאורטית של הזמנת שירותי בניה) באם רצונם למכור את זכויותיהם בחניות לריזו אם לאו.

אעיר כי גם לא מצאתי הגבלה בהסכם על מספר החניות אותם זכאי כל אחד מיחיד הבעלים לממן ולרכוש. ההסכם מקצה לכל בעלי הדירות זכות לממן 10 חניות על פי הגרלה בניהם. לכאורה, אם אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים יהיה מעוניין במימון מקום חניה, יהיו זכאים ריזו לממן את כל או כל חלק ממכסת מקומות החניה לבעלים ולקבל 10 חניות ללא צורך ברכישת חניה מהבעלים האחרים (כפי שיידרש בעסקת בניה עצמית). נדמה כי אם בכך היו תלויים הדברים ניתן היה להגיע להסכמות בין בעלי הדירות מראש על הקצאת מקומות חניה נוספים לריזו, בפרט כאשר אין מחלוקת שישנם בעלי דירות בבית שאין להם הכספים הנדרשים למימון הבניה וממילא למימון עלות החניות המוערכת בסך של כ- 200,000 ₪ לחניה (מוצג 1/1).

זאת ועוד. על פי הסכם הקומבינציה החניות יוקצו לכל הצדדים, כולל היזם, על פי הגרלה שתיערך, כאשר ליזם תהיה הזכות לבחור רק את 5 מקומות החניה הראשונים. אינני רואה בחלוקת החניות כאמור משום פגיעה מהותית בריזו.

מכל מקום, כאמור לעיל, חלופת הזמנת שירותי בניה או חלופת עסקה משולבת ממילא אינן רלבנטיות במקרה דנן.

בכל הקשור לחלופה שעניינה פירוק השיתוף, הרי שמן הראיות שהוצגו בפני עולה כי לא רק שסוגיית מרתפי החניה לא תועיל לתמורה שתתקבל בגין מכירה אלא שהיא אף עשויה להפחית מתמורה זו, לאור הקשיים שבבניה במקום זה, כפי שמעיד מר עמיאל – "החניון זה הסיפור עם הכי הרבה חוסר ודאות. הקרקע שם היא קרקע בעייתית, לכן גם יועץ קרקע ששכרנו לא יודע להעריך כרגע מה יהיה סוג הביסוס. הביסוס יהיה כנראה בשיטת "סלארי" פה עובי הקיר הוא 60 ס"מ



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

והגובה הוא פי 3. העומק הוא בין 18-20 ס"מ ואת זה נדע רק כשנתחיל לבנות. אז דיברו על \$500 למטר מעוקב בטון. אני צופה שהמרתף הזה יעלה בין 3-5 מליון ₪ על כל העלויות כפי שהן פורטו בהסכם" (עמוד 42 שורות 6-10). לכך יש להוסיף גם את הנסיבות העובדתיות, שאינן שנויות במחלוקת, ומצבם הפיזי של יסודות הבית אשר הביאו להריסת רבע מהבית על אף עבודות מיסוד שבוצעו.

לאור כל האמור לעיל הרי שאין כל פירות בזכויות ריז בין חלופת קימום הבית על פי החלטת הרוב לבין חלופת ביטול הרישום ופירוק השיתוף.

האם החלטת השיקום פוגעת בשוויון

על פי חוות הדעת של מר אברהמוב הדירה המוצעת לריז במסגרת ההסכם קטנה ב- 7% לעומת הדירות שיקבלו התובעים. הפרש זה נאמד על ידו בסך של 246,400 ₪. כמו כן אמורים ריז לקבל דירה אחת במקום 2 דירות על פי היתר הבניה המקורי ולפיכך המדובר בפגיעה נוספת בסך של 352,000 ₪. ובסך הכל ישנו הפרש של כ- 600,000 ₪ בהשוואה לדירות שיקבלו הבעלים האחרים.

אין בידי לקבל את חוות הדעת בהקשר זה.

מתשריט היתר הבניה שצורף לחוות הדעת עולה כי דירת ריז הינה, למעשה, 2 דירות מחוברות שגודלן זהה ל- 2 הדירות הממוקמות ישירות מעל דירתם בקומות שמעל ומתחת לדירתם. משכך, בהתאם להיתר הבניה דירת ריז צריכה להיות כפולה בגודלה מהדירות הטיפוסיות האחרות בבית.

בהיתר הבניה שצורף חושבו שטחי המגורים בכל קומה (196.76 מ"ר) ואלו מחולקים ל- 4 דירות בכל קומה (בהפחתת כ- 11.5 מ"ר שטחים ציבוריים לחדרי מדרגות), קרי, כל דירה סטנדרטית גודלה כ- 46 מ"ר כאשר דירת ריז גודלה 92 מ"ר.

גם הבניה החדשה המתוכננת כוללת בניה של 4 דירות בשטח קומה כאשר קווי הבניין מורחבים ככל האפשר בכל קומה, כפי שמעיד מר עמיאל – "באו אלי הדיירים ואמרו לי שהם רוצים להקים את הבניין החדש באופן שכל דייר יקבל דירה שהיא זהה במיקום למיקום הקודם שהיה לה ובגודל המרבי שאני יכול להציע להם. עם כל הדירות מעל הקרקע לא הייתה בעיה כי אני הלכתי הפוך מהלוגיקה של היזם. התחייבתי שמקסימום מטרים שניתן לעשות בכול קומה, שמה שקובע זה התכנית המותרת, אני אנצל ואז זה פותר מה מקבל כל אחד מהדיירים מעל הקרקע" (עמוד 44 שורה 17).

הבניה החדשה המתוכננת שומרת על יחס שווה בין דירת ריז (110 מ"ר מתוכננים 2 מרפסות) לבין הדירות האחרות (55 מ"ר מתוכננים ומרפסת) (ר' סעיף 31 להסכם הקומבינציה).

גם מר אברהמוב מאשר בעדותו כי חלוקת הדירות לבעלים איננה על פי חלקם היחסי ברכוש המשותף אלא החזרה של הדירות הספציפיות של כל אחד מהם - "לא נקבע בהסכם עם עמיאל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שיעור אחוז אלה דירות ספציפיות. ש.ת. כל אחר אמור לקבל דירה לא את אותה דירה" (עמוד 49 שורות 14-16).

גם תשריט הבית המשותף (המצוי בידיעתי השיפוטית) תומך בכך שאין כל פגיעה בשוויון בפעולת השיקום המתוכננת.

מתשריט הבית המשותף נלמד כי קונטור דירת רייז (קירותיה החיצוניים) והמרפסות, זהים לקונטור 2 הדירות הממוקמות מעל לדירת רייז ו- 2 הדירות הממוקמות מתחת לדירתם. **משכך, פיזית לא יכול להיות הבדל בגודל הדירות.**

אומנם, על פי המידות המפורטות בטבלה שבתשריט, שטח רצפת דירת רייז גדול יותר מאשר שטח רצפת 2 הדירות שמעל ומתחת. אולם, עיון בתשריט מלמד כי בכל אחת מהדירות הקטנות קיימת מרפסת שירות מן המטבח, אשר לא נספרה בשטח הרצפות בעוד בדירת רייז (המאחדת שתי דירות כאמור) אוחדו מרפסות שירות כחלק מחדרי הבית ושטח זה נמדד.

יוצא כי, מבחינת "מידות" השטח המפורטות בצו הרישום לכאורה ישנה פגיעה מסוימת בזכויות רייז. אולם, מרגע שהוחלט על ביצוע הבניה כפי שצוטט לעיל (חלוקת כל קומה ל- 4 כאשר דירת רייז מאחדת 2 דירות), הרי שאין כל ממש בטענה זו בגין פגיעה – רייז מקבלים בהסכם הקומבינציה חלק יחסי שווה לזה שהיה להם בפועל, הן על פי היתר הבניה והן על פי מסמכי רישום הבית המשותף ולזה שמקבלים בעלי הדירות האחרים בבית. ויודגש, ממילא את אותן הזכויות בדיוק היו מקבלים רייז בגין דירתם גם בחלופה המוצעת על ידם של שיקום הבית על ידי מימון עצמי.

גם אין כל ממש בטענת מר אברהמוב בגין פגיעה בזכויות רייז עת מתוכננת להיבנות עבורם דירה אחת בלבד ולא שתי דירות, כפי שאושר בהיתר הבניה המקורי.

בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף לרייז זכויות בדירה אחת בלבד בבית. אלו הן הזכויות הקנייניות שבידי רייז ואלו הן הזכויות להם הם זכאים בעת קימום הבית על פי סעיף 60 לחוק המקרקעין.

למעשה, טענת מר אברהמוב בדבר זכאותם של רייז ל- 2 דירות הינה "שיפור" או "שינוי" למצבם של רייז עובר להריסת הבית ובוודאי שלא ניתן להתייחס לכך כפגיעה בשוויון. ההפך הוא הנכון. הסכם הקומבינציה מביא להקמתו של הבית מחדש והחזרת הדירות שהיו בעבר לבעליהם. עצם הדרישה לפיצול דירתם של רייז ל- 2 דירות, בניגוד למצב זכויותיהם הקנייניות, הינה הפוגעת בשוויון, מעדיפה את רייז על פני בעלי הדירות האחרים ומשפרת, לכאורה, את שווי זכויותיו.

למר אברהמוב טענות נוספות בגין פגיעה בזכויות רייז עקב הסכם הקומבינציה.

כך, נטען כי התובעת 5 מקבלת בהסכם הקומבינציה יותר מכפי שווי זכויותיה בבית. בהקשר זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נטען כי הגב' ינוב זכאית למקדם אקוויוולנטי עיקרי של 22 מ"ר על שטח המחסן הרשום לזכותה בצו רישום הבית המשותף. לא ברורה ממש טענת מר אברהמוב בהקשר זה. בסיסו של הסכם הקומבינציה הוא כזה שבעלי הדירות מקבלים בחזרה את דירותיהם (בגודל המקסימלי האפשרי לאור מגבלות התכנון) וכל יתר הזכויות עוברות לידי עמיאל כתמורה לקימום הבית. משכך, ככל שהתובעת 5 מקבלת יותר מכפי חלקה היחסי במקרקעין הרי שהמדובר ממילא בהפחתה של התמורה לה זכאי עמיאל ואין בכך לבוא על חשבון זכויות בעלי הדירות האחרים. זאת ועוד. על פי הסכם הקומבינציה זכויותיה של הגב' ינוב יקבעו ע"י שמאית מוסכמת ולפיכך יתכן וממילא זו תאמץ את טענותיו של מר אברהמוב בנוגע לזכויות המגיעות לגב' ינוב, ומכל מקום, ישמר השוויון בין בעלי הדירות מבחינת שווי זכויותיהם.

אעיר עוד בהקשר זה כי היה ולא יקומם הבית ויפורק השיתוף בו, תהיה התובעת 5 בעלים של 73/761 חלקים מהמקרקעין בהתאם לחלקה היחסי ברכוש המשותף. בחלופה שכזו ברי כי "שווי" זכויותיה יהיה גדול יותר.

כך, נטען כי שוויון של "דירות גן" הכוללות גינה פרטית גבוהה מאשר דירה בקומה הראשונה ולכך יש לתת ביטוי באיזון בן הדיירים. נטען גם כי דירות היזם ימוקמו גבוה יותר בבית ומשכך יהיו הן גם יקרות יותר.

בכל הקשור לדירות היזם הרי, כאמור לעיל, בידינו ניתנו הזכויות לבניה נוספת בבית כתמורה לקימום הבית על ידו. העובדה כי היזם עשוי להרוויח או כי שווי דירותיו יהיה גבוה מדירות הבעלים, אין בה להעלות או להוריד בשאלת השוויון. בתמורה לזכויות הניתנות ליזם הוא בונה מחדש את הבית ומחזיר לבעלי הדירות את דירותיהם. ברי כי גם רוח יכול להיות ליזם בעסקה מסוג זה.

בכל הקשור ל"דירות הגן" אעיר כי על פי סעיפים 31.1 ו- 31.2 להסכם השיתוף לא זכאיות התובעות 5 ו- 6 לדירות גן אלא אך לדירות בקומת הקרקע.

מכל מקום, הסכם הקומבינציה כולל בחובו, באופן אינהרנטי את "הגנת החבות", לא רק לרייז אלא לכל בעלי הדירות בבית. כך, סעיף 30 להסכם הקומבינציה קובע פרוצדורה לעריכת טבלאות איזון ע"י שמאית מוסכמת בין ערך הדירות בבית לבין ערך הדירות בבית החדש. עוד קובע הסעיף האמור חיוב בביצוע תשלומי איזון על פי הקביעה האמורה.

בכך באה לידי פתרון כל טענה של פגיעה או ירידת ערך בזכויות מי מהצדדים או פגיעה כלשהי בשוויון בקבלת הזכויות (לרבות בנושא שווי הזכויות שתקבל התובעת 5 או בנוגע לדירות הגן). דרך זו היא גם הנאותה ביותר להסדיר כל "פיחות" אפשרי בזכויות מי מהצדדים.

לפני סיום פרק זה אעיר כי חוות הדעת של מר אברהמוב מתאימה לנסיבות בהן המדובר בבעלות משותפת במקרקעין אשר מבקשים להשיא את התשואות הימנה. כך הוא בחן את ההתקשרות – "אני עברתי על ההסכם עם מר עמיאל, אבל לא נכנסתי לכל הסוגיות. ש.ת. זו לגבי לא עסקת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

קומבינציה מקובלת. ש.ת. עסקת קומבינציה זו שניתנת קרקע בתמורה לדירות שזכויות הבעלים נשמרות. אם על ידי שיעור הקומבינציה או לחילופין ניתנת לבעלי הקרקע האפשרות להזמין שירותי בניה" (עמוד 49 שורות 10-11).

דא עקא, אין זהו המקרה שבפנינו - המדובר בבית משותף אשר מבוקש להקימו מחדש, ולא רק שיקולי כדאיות כלכלית נכנסים במערך השיקולים. תפיסת הקניין המסורתית מפנה את מקומה במקרה דנן למודל נורמטיבי מיוחד ולשיקולים בר קנייניים מסורתיים כפי שצוטט לעיל.

האם פעלו המשקמים בתום לב

לאחר ששקלתי את כל הראיות שנשמעו בפני אין בידי להסכים עם טענת ריז כי התובעים פעלו בחוסר תום לב.

מן הראיות עולה כי היה מאמץ משותף שנמשך שנים בכדי להביא להחלטות מוסכמות לקימום הבית - החלטת האסיפה הכללית מיום 20.07.08 התקבלה כדין לאחר בחינת חלופות אפשריות לביצוע העסקה על ידי בעלי דירות. גם מר ריז השתתף באותה האסיפה (ר' תיאורו בעמוד 53 שורות 16-30).

בהקשר זה אעיר כי אין בידי לקבל את טענת ריז כאילו הפרוטוקול אינו משקף את אשר אירע באותה אסיפה. למעט העובדה כי הפרוטוקול נתמך בעדויות התובעים כמצוטט לעיל, הרי שריז לא פנו "בזמן אמת" בבקשה לתיקון הפרוטוקול או בטענה כי אין הוא משקף את אשר הוחלט (עמוד 54 שורות 1-5). רק לאחר שחזרו בהם מהסכמתם לביצוע עסקת קומבינציה "נזכרו" לטעון כי הצבעתם באותה אסיפה היתה שונה.

אף לאחר שהתגלעו סכסוכים בין התובעים לריז בנוגע לדרך השיקום, שבו הצדדים והגיעו להסכמות בהחלטת האסיפה מיום 09.02.10.

לא ניתן לומר כי התנהלות התובעים לפני, במהלך ואחרי האסיפה מיום 09.02.10 היתה חסרת תום לב. די לעיין בהתכתבות העניפה שבין הצדדים ובאי כוחם (ר' מוצגים יב' עד כב' לתיק מוצגי התביעה) ובתיאור השתלשלות המו"מ בין הצדדים הן בעדותו של מר סמואל והן בעדותו של מר פרידמן, כדי להבין שלא היה כל ניסיון מצד התובעים להכשיל את מימוש ההחלטה מיום 09.02.10. כך גם עולה מעדותו של מר ריז (עמוד 57 שורות 12-27).

גם לא התרשמתי כי היה ניסיון כלשהו למדר את ריז מקבלת ההחלטות בנוגע להליכי השיקום. מן הראיות עולה כי ריז היו מעורבים לפרטי פרטים, שהרי אף הסכימו, בסופו של יום, לחתום על הסכם הקומבינציה כפי שזה נחתם עם עמיאל (למעט בנושא שכ"ט עוה"ד). ויש לזכור, מר ריז, לווה בשלבים אלו על ידי עו"ד פרידמן וממילא גם הוא עצמו אינו הדיוט בתחום הנדל"ן (עמוד 54 שורות 6-8) ואין זה סביר כי הסכים לעסקה המשמעותית המוצעת ללא שבידיו כל הנתונים הנדרשים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין בידי לקבל את טענת ריזו כי בעלי הדירות בבית אינם מודעים למשמעות ההסכם שנחתם או קיבלו "החלטה פזיזה" או כי הם "חפצים ביקרם של עמיאל ושל עו"ד סמואל" (סעיף 49 לסיכומים). טבעם של דברים שאנשים אינם מוותרים על זכויותיהם כלל ובודאי שלו בקלות יתרה. ברי כי לו היו סבורים בעלי הדירות, או למצער חלק מהם, כי ניתן להביא לקימום הבית בחלופה אחרת אשר תמקסם את רווחי כל בעלי הדירות, היו פועלים הם ליזום פעולה שכזו. בפרט אמורים הדברים כאשר המדובר בהליכים המתנהלים על פני למעלה מעשור מאז נאסר השימוש בבית ובהליכים משפטיים המתנהלים כבר למעלה משנה. הדברים גם הוצגו לבעלי הדירות, לכל הפחות, באסיפה מיום 09.02.10 בסופה הוסכם בין כולם על קימום הבית על פי המתווה המוסכם, כאשר השאלה היחידה שנותרה היתה זהות המבצע ולא שאלת דרך קימום הבית.

מן העדויות שנשמעו בפני התרשמותי כי התובעים שקלו את כל החלופות הרלבנטיות והתקשרותם עם עמיאל נעשתה בידיעה והבנה כי זוהי העסקה המיטבית הקיימת. כך מעיד מר שניצר - "ב-2009-2010 שקלנו לעשות עסקה משולבת. קיבלנו החלטה באסיפת הדיירים ללכת על הקומבינציה אני לאישי לא יכול לממן אז זה לא רלוונטי וגם לעוד תשעה לפחות זה לא רלוונטי" (עמוד 40 שורות 7-8). מר שניצר אף תמך בתחילה בחלופה של פירוק השיתוף אולם השכיל לפעול על פי החלטת הרוב (עמוד 40 שורה 3). גם מר רבה מעיד "אם היו מציעים לי לשלם 400,000 ולקבל דירה בנויה - אף פעם לא נכנסתי לזה, לא חשבתי על זה. אני אף פעם לא חשבתי על זה, על הרבה אופציות, הלכתי עם ההצעה הטובה שקיבלנו מגדי עמיאל" (עמוד 38 שורות 13-15). כך גם מעיד מר גוזלן - "בעסקה משולבת לא היה קם הבניין" (עמוד 37 שורה 23).

כאמור, ההחלטה לשיקום הבית התקבלה כדין. אולם, צודקים ריזו בטענתם כי במסגרת החלטה זו לא נכלל גם אישור הסכם שכר טרחתו של עו"ד סמואל.

אם ההתקשרות עם עו"ד הינה חלק מהליכי שיקום הבית (ואינני פוסל את האפשרות כי במסגרת הליכי השיקום תתקבל החלטה גם על העסקתם של אנשי מקצוע אשר יש בידם להביא למיצוי זכויות הבעלים או להבטחת ביצוע מקצועי ואיכותי של העבודות), הרי שנדרשת החלטה כדין בהקשר זה וברוב הדרוש. דא עקא, מן הראיות שבפני עולה כי הדרישה לתשלום שכר הטרחה לייצוג בעלי הדירות על ידי עו"ד סמואל מקורה בהסכם עליו חתמה הנציגות בלבד (מוצג כד לתיק מוצגי התובעים וכן עמוד 39 שורה 20). לא הוצג בפני כל הסכם חתום על ידי ריזו וגם לא כל החלטה של רוב נדרש של בעלי הדירות המאשרת את הסכם הייצוג האמור בנוגע למימוש הפרויקט לקימום הבית באמצעות עסקת קומבינציה. למעשה, לא נטען כלל כי קיימים הסכם או החלטה כנ"ל. מעדותו של מר שניצר בהקשר זה עולה כי הוא אפילו אינו זוכר אם הודע בכלל לבעלי הדירות בנוגע להסכם שכר הטרחה שחתמה הנציגות עם עו"ד סמואל (עמוד 39 שורות 20-23). כך גם עולה מתצהירה של הגב' בליצקי שלא נחקרה נגדית על תצהירה (סעיפים 14-15 לתצהיר).

אומנם, התובעים הכריזו על עו"ד סמואל כמיצגם בהסכם הקומבינציה (סעיפים 61 ואילך לחוזה). אולם, אין בכך די כדי לחייב גם את ריזו להיות מיוצגים בהסכם על ידי עו"ד סמואל ובודאי שאין בכך כדי להביא בחיובם לשאת בתשלום שכר טרחתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין באמור כדי לפטור את ריז מלשתף פעולה עם התובעים ועמאל בכל הקשור להוצאתו לפועל של הסכם הקומבינציה או כדי להוות "הכשר" לעיכוב ביצוע שיקום הבית במהירות וביעילות על פי הסכם הקומבינציה. בכלל האמור על ריז למנות בא כוח מטעם (על פי סעיף 61 להסכם הקומבינציה) ולחתום על יפוי כח בלתי חוזר (בין היתר על פי סעיפים 40-41 להסכם הקומבינציה) המסמך את בא כוחם ואת בא כוח עמאל. ברי כי על ריז תהיה החובה לשאת בתשלום שכרו של בא כוחם. אולם, ככל שעמאל יישא בתשלום שכר טרחת בא כוח התובעים, יהיה עליו לשאת גם בתשלום שכר טרחת בא כוח ריז באופן שוויוני על פי חלקו היחסי.

למעשה, מרגע שפסקתי כאמור, כי לא ניתן לחייב את ריז בתשלום שכרו של סמואל או ביצוגם על ידו במסגרת ההסכם, מניה וביה הוסר כל טעם התנגדות של ריז להסכם שנחתם עם עמאל, שהרי, כאמור, הם היו נכונים לחתום על הסכם זה, בתנאים אלו, כיום הפרוייקט. קרי, כבעלים היו ריז מקבלים בדיוק את אשר ניתן להם, גם עתה, במסגרת הסכם הקומבינציה.

יוצא כי התובעים עמדו בתנאים אשר נקבעו בהלכה לתחולתו של סעיף 60 לחוק המקרקעין - התקבלה החלטת משקמים ודרך השיקום שנבחרה עומדת במבחן הסבירות - חלופת השיקום עדיפה על פני חלופת פירוק השיתוף, אין פגיעה בשוויון ולא היה דופי בהתנהלות המשקמים. לפיכך, ניתן לחייב את ריז בקימום הבית על פי הסכם הקומבינציה למעט בנושא החיוב בתשלום שכר הטרחה של עוה"ד סמואל או בייצוגו של האחרון אותם במסגרת ההסכם.

לפני סיום אבהיר כי אין בידי לקבל את פרשנות ריז לפסק הדין בפרשת צודלר ואבחוננו המוצע של המקרה דנן.

ראשית, גם במקרה דנן, כמו בפרשת צודלר, עומדות להכרעה שתי חלופות בלבד - קימום הבית על פי החלטת הרוב או ביטולו ופירוק השיתוף בין בעלי הזכויות כאמור לעיל.

שנית, אומנם, בפרשת צודלר "קיבלו" בעלי הדירות במסגרת ההסכם עם העירייה זכויות בניה נוספות שלא היו מוקנות להם קודם לכן (בניגוד למקרה דנן בו לבעלי הדירות זכויות מוקנות ללא קשר להליכי השיקום). אולם, אין בכך לשנות מבחינה מהותית את התוצאה של החלטת העקרונות שנקבעו בפרשת צודלר. אף שהזכויות קיימות, הרי שבמקרה דנן ללא הסכמה של בעלי הדירות בבית (ברוב הדרוש) לא ניתן לממשן בפועל. משכך, גם כאן המדובר בזכויות בניה התלויות (מבחינת מימוש) בקימום הבית על פי סעיף 60 לחוק המקרקעין.

ויודגש, אומנם, בניגוד לפרשת צודלר, בחלופת פירוק השיתוף יש לכלול זכויות אלו בחישוב שווי הזכויות (כפי שנעשה לעיל). דא עקא, כאמור לעיל, במקרה דנן הוכח כי אין פיתוח בזכויות ריז בין חלופת פירוק השיתוף (כולל כל זכויות הבניה) לבין חלופת קימום הבית. משכך, אין נפקות להבחנה האמורה.

שלישית, אין כל הבדל באם אישר את השיקום רוב של 80.4% מבעלי הרכוש המשותף (במקרה דנן) או רוב של 93% מבעלי הדירות (בפרשת צודלר), מרגע שיש בידי המשקמים את הרוב הנדרש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהתאם להוראות סעיף 60 לחוק. המחוקק הוא זה אשר קבע את "רף ההסכמה" הנדרש ומשזה מתקיים, אין זה בסמכותו של המפקח להחליט על "העלאת" רף זה. לבד מכך הרי שבמקרה דנן, לאור עמדת הנתבע 4 בהליך בפני, נותרו ריזי כיום בודדים בסירובם.

רביעית, ההכרעה בפרשת צודלר איננה מבוססת רק על כך שבעלי הדירות שם קיבלו דירות גדולות יותר או כי ישנו הפרש משמעותי בין "שווי" הזכויות בחלופת המימוש וחלופת פירוק השיתוף. ההכרעה העקרונית שם התבססה על בחינת זכויות הקניין בבית המשותף על רכיביו המיוחדים. גודל היחידות שניתן לקבל הינו תוצאה של מגבלות תכנוניות ופיזיות של המקרקעין. במקרה דנן, כאמור לעיל, לא ניתן לבנות דירות גדולות יותר כאשר נשמר העיקרון שכל בעל דירה יקבל בחזרה את דירתו שהיתה, במקום שהיתה. אומנם, בפרשת צודלר קיבלו בעלי הדירות יותר. אולם, גם היה להם יותר "לתת" ליזמים בתמורה, לאור ההגדלה המשמעותית של זכויות הבניה על ידי העירייה. למרבה הצער, במקרה דנן, "העוגה" איננה כה גדולה.

יש גם לזכור כי בפרשת צודלר המחזו בעלי הדירות את זכותם לקבלת הפיצויים ממס רכוש לטובת העירייה. כלומר, בעלי הדירות אף "שילמו" כספים נוספים עבור קימום הבית (מעבר לזכויות הבניה שהוקנו ליזמים) ולכן גם "קיבלו" יותר. במקרה דנן לא נדרשים בעלי הדירות לכל תשלום נוסף.

חמישית, בדומה לפרשת צודלר, כך גם כאן, לא ממש ברור על מה יצא קצפה של התנגדות ריזי. החלופה של פירוק שיתוף היא האלטרנטיבה היחידה לקימום הבית וזו צפויה לגרום לפיחות ברור בשווי זכויותיהם כבעלים. הציפיות לתשואה גבוהה יותר, שאינן מבוססות על עסקאות בעלות התכנות משפטית (בהעדר הסכמה של בעלי הדירות) או עובדתית (בהעדר יום) אינן סיבה מספיק טובה להתנגדות לחלופה הריאלית העדיפה הקיימת.

וידוגש, ריזי הסכימו לחתום כיום על ההסכם לקימום הבית, ככתבו וכלשונו, וכל שעמד בדרכם היה נושא הייצוג המשפטי במסגרת ההסכם. כלומר, גם הם היו מודעים לכך שהמדובר בחלופה העדיפה ביותר לבעלי הדירות בבית וממילא הם מקבלים בהסכם הקומביניציה את אשר היו מקבלים (כבעלים) לו היו הם נוטלים על עצמם את מלאכת קימום הבית. נדמה כי לריזי ישנו קושי להשלים עם החלטות הרוב שאינן תואמות את ציפיותיהם (עמוד 49 שורות 30-31).

סופו של יום, כמו בפרשת צודלר, כך גם במקרה דנן, המדובר בבני אדם אשר מבקשים לשוב ולקומם את ביתם ולחזור ולגור בו, במקרה דנן לאחר תקופה של למעלה מעשור שנים. זאת ועוד. בהליך דנן אין המדובר בהכרעה בין דרכים שונות לשקם את הבית כאמור לעיל אלא בהכרעה בין הקמתו בדרך שמבקש הרוב לבין אי הקמתו של הבית מחדש תוך ביטול הרישום ופירוק השיתוף. בנסיבות דנן, כאשר כל בעלי הדירות בבית, כולל הנתבעים, מעוניינים בחלופת שיקום הבית, יש להעדיף את הבחירה בדרך זו תוך העניקה של "הגנת החבות", כפי שזו ניתנת, למעשה, בהסכם הקומביניציה כאמור.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 128/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי הנסח הרשום הנתבעת 1 הינה הבעלים של דירת רייז ולפיכך אני מצווה על הנתבעת 1, ככל שלא תחתום על הסכם הקומבינציה בתוך 14 יום מהיום, להעביר בתוך 6 חודשים מהיום את זכויותיה בדירה לאדם אחר אשר היא תקבע ואשר יבוא במקומה בכל הקשור לקימום הבית ויחתום על הסכם הקומבינציה שבין התובעים לעמיאל.

לא תפעל הנתבעת 1 כאמור לעיל יהיו רשאים התובעים לפנות בבקשה בהתאם להוראות סעיף 60(ג) לחוק המקרקעין.

כאמור לעיל, הנתבעת 1 תהיה רשאית להיות מיוצגת במסגרת הסכם הקומבינציה על ידי בא כח מטעמה.

אף אם הנתבעים 2 ו-3 הינם "המוטבים הסופיים" של הדירה, אין בכך די כדי לחייבם בסעד המבוקש בהליך דנן בהתאם להוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין ולפיכך אני מורה על מחיקת התביעה כנגדם.

הנתבעת 1 תשלם לתובעים סך של 616 ₪ בגין החזר הוצאות אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן תשלם הנתבעת 1 לתובעים סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות עדות מר סמואל וסך של 20,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו ישיבת קדם, 3 ישיבות הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.

לאור הסכמתו של הנתבע 4 להצטרף לכל החלטת בניה שתתקבל, ניתנת לנתבע 4 שהות בת 14 יום לחתום על הסכם הקומבינציה. לא יעשה כן, יהיה על הנתבע 4 להעביר בתוך 6 חודשים מהיום את זכויותיו בדירה לאדם אחר אשר הוא יקבע ואשר יבוא במקומו בכל הקשור לקימום הבית ויחתום על הסכם הקומבינציה שבין התובעים לעמיאל.

לא יפעל הנתבע 4 כאמור לעיל, יהיו רשאים התובעים לפנות בבקשה בהתאם להוראות סעיף 60(ג) לחוק המקרקעין.

לאור הסכמתו של הנתבע 4 מראש לכל אשר יפסק בהליך זה כאמור לעיל אינני מוצא מקום לחייבו בהוצאות ההליך.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום כ"א אייר תשע"ב, 13 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב